

0000645-13.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Ezaú Messias dos Santos

Comarca: Itatiba

Foro: Foro de Itatiba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... de condenação, deve ser observado o tráfico-privilegiado e responder em liberdade (fls. 473/500).

A Defesa de Paulo Sérgio, em suma, pediu o reconhecimento de condições favoráveis na aplicação da pena e afastamento do crime de associação para o tráfico (fls. 515/523).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas são aptas à condenação apenas dos réus Paulo Sérgio e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Vara Criminal de Itatiba

Processo nº 0000645-13.2021.8.26.0544 Fls. de

Aos 25 de janeiro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da Vara Criminal da Comarca de Itatiba, Estado de São Paulo, Doutor EZAÚ MESSIAS DOS SANTOS.

Assistente Jud.: Thiago André Busso - M. 365.013

SENTENÇA

VISTOS.

VINÍCIUS GUSTAVO REIS, PAULO SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA e MATHEUS DA SILVA SERRADILHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, porque em local e data incerta, mas anterior a 04 de outubro de 2021, associaram-se para o fim de praticar tráfico de drogas, e na tarde do referido dia, no pátio do posto Morro Azul, localizado no km 95, sentido sul, da Rodovia Dom Pedro I, nesta cidade e comarca, transportavam para entrega a consumo de terceiros oitenta e cinco tabletes de cocaína, pesando mais de 87 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo a denúncia, policiais rodoviários suspeitaram de indivíduos que retiravam bolsas do interior de um caminhão parado no pátio de um posto às margens da rodovia e colocavam num veículo Renault Sandero. Feita a abordagem, localizaram os pacotes com a droga dentro do carro, e mais R\$ 40.900,00 dentro do caminhão Volvo, cujo condutor, Matheus, admitiu ter recebido R\$ 30.000,00 para transportá-la desde Cuiabá/MT e entregar no local, enquanto Paulo Sérgio admitiu que receberia R\$ 3.000,00 para buscar a droga nesta cidade, ao passo que Vinicius alegou ter sido contratado por fazer serviço de transporte por aplicativo.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva na audiência de custódia (fls. 228/230), os réus foram notificados e citados e os defensores apresentaram defesas prévias (fls. 376/378 e 389/396), sendo recebida a denúncia e o aditamento feito em audiência para incluir a causa de aumento de pena pelo transporte interestadual (fls. 419).

Em audiência de instrução por videoconferência, foram colhidos e gravados os depoimentos dos policiais rodoviários e os interrogatórios, seguindo-se alegações finais em que o representante do Ministério Público pediu a condenação dos réus

Paulo Sérgio e Matheus nos termos da denúncia e aditamento e a absolvição de Vinicius por falta de provas de participação nos crimes imputados (fls. 428/437), no que, em suma, foi seguido pela Defesa de Vinicius (fls. 443/449), o qual foi colocado em liberdade (fls. 450/451).

A Defesa de Matheus, em resumo, pediu a absolvição alegando que agiu sob a excludente da inexigibilidade de conduta diversa a fim de conseguir dinheiro pra o tratamento médico de sua mãe; que apenas agiu como "mula", fazendo o transporte da droga para o qual foi cooptado, sem intenção de participar de associação criminosa; que, em caso de condenação, deve ser observado o tráfico-privilegiado e responder em liberdade (fls. 473/500).

A Defesa de Paulo Sérgio, em suma, pediu o reconhecimento de condições favoráveis na aplicação da pena e afastamento do crime de associação para o tráfico (fls. 515/523).

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

As provas são aptas à condenação apenas dos réus Paulo Sérgio e Matheus pelo crime de tráfico de drogas.

Vejam os.

A materialidade está estampada no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 239/242) que resultou positivo para a presença do princípio ativo na substância apreendida, qual seja, cocaína-base.

Não há dúvidas quanto à destinação da droga para o tráfico quando nada pelo vultoso volume apreendido, mais de 87 kg de cocaína-base.

A análise da prova permite concluir pela autoria em relação a dois dos acusados presos em flagrante pela polícia rodoviária, absolvendo-se o réu Vinicius, posto que não ficou evidenciado que fazia parte da associação criminosa, mas apenas fora contratado como motorista por aplicativo.

Vejam os.

Matheus, tanto na delegacia quanto em juízo, alegou que foi cooptado a fim de transportar a droga de Cuiabá/MT e entregar num posto na Rodovia D. Pedro I, pelo que receberia R\$ 30.000,00.

Alegou que carregou o caminhão no frigorífico Marfrig para levar a carga de carne para o Rio de Janeiro. Entretanto, quando aguardava o carregamento num trailer na frente da empresa ficou conversando com um indivíduo e falou de sua condição financeira e que sua mãe estava doente, aceitando, por fim, a proposta de ganhar R\$ 30.000,00 para transportar bolsas com droga na boleia do caminhão e entregar no posto Morro Azul, na Rodovia D. Pedro I.

Aduziu que assim que estacionou o caminhão no pátio do posto indivíduos se aproximaram e lhe entregaram uma caixa com dinheiro, retiraram as sacolas do caminhão e colocaram num carro, mas momentos depois foram abordados pelos policiais e presos.

Paulo Sérgio, por sua vez, quando da lavratura do flagrante, admitiu que iria receber R\$ 3.000,00 pelo serviço de buscar a droga num posto e levar para outro lugar.

Em juízo, alegou que depois que saiu da prisão em que foram apreendidos num caminhão de mudança que dirigia 218 kg de cocaína, foi localizado e ameaçado por indivíduos que diziam que deveria "pagar a conta".

Assim, por celular, foi orientado a pegar um Uber, ir até a avenida Mutinga, em Osasco, onde um motoboy lhe entregou um caixa com dinheiro e depois veio até o posto na Rodovia D. Pedro I para pegar as sacolas com o motorista de um caminhão e lhe entregar o dinheiro. Porém, na saída do posto para a rodovia foram abordados pelos policiais rodoviários.

Vinicius, por sua vez, sempre manteve a mesma versão de que, fazendo serviço como motorista de transporte por aplicativo, aceitou fazer uma corrida até a região de Campinas. Assim, ao parar num posto, o passageiro pegou as sacolas num caminhão e na saída de volta para a rodovia foram abordados pelos policiais.

Acrescentou que o carro era alugado de um amigo e pagava R\$ 400,00 por semana; que houve indicação de um colega para fazer o serviço; pegou o passageiro no local

combinado, na zona leste de São Paulo; depois ele pegou uma sacola com um motoboy numa avenida em Osasco e em seguida vieram até o posto nesta cidade, onde foram presos, negando ter conhecimento da droga apreendida.

Os policiais rodoviários, em essência, confirmaram as versões dos réus, relatando que resolveram abordar os ocupantes de um veículo que viram retirando sacolas de um caminhão parado num posto e acharam a droga acondicionada em tabletes no porta-malas de um carro.

O PM Gomide informou que em patrulhamento suspeitaram de indivíduos que viram colocando bolsas retiradas da cabine de um caminhão no porta-malas de um carro e quando saía do posto fizeram a abordagem e apreenderam os tabletes com aparentemente pasta-base de cocaína.

Disseram os policiais que Vinicius alegou ser apenas motorista por aplicativo e que fora contratado para fazer o serviço de transporte de passageiro; Paulo Sérgio teria falado que pegou o dinheiro com um motoboy e entregou para o motorista do caminhão e este, Matheus, admitiu saber que transportava drogas e que recebera R\$ 30.000,00 pelo serviço, sendo apreendido o dinheiro dentro do caminhão que conduzia.

Diante deste quadro, ressuma evidenciado que o motorista de caminhão Matheus aceitou fazer o trabalho de "mula", ou seja, transportar a droga dentro do caminhão e entregar num posto, a fim de receber dinheiro, incorrendo, pois, no tipo penal em apreço, na modalidade transportar.

E, à míngua de prova, soa como vão artifício de defesa a alegação de que agiu sob a excludente da inexigibilidade de conduta diversa, quando nada porque caberia à defesa demonstrar a excludente de culpabilidade, do que não se desincumbiu, seja porque resultou clarificado que, por cupidez ou ganância exacerbada, enveredou o motorista pelo caminho fácil de ganhar dinheiro, mas se deu mal, posto que, mal pôs a mão no capital espúrio, a polícia rodoviária, sempre vigilante e altaneira, em trabalho de envergadura e tirocínio aguçado de seus membros, lhe pôs a mão pesada nos ombros.

Da mesma forma, não se desincumbiu Paulo Sérgio de demonstrar que fora coagido a fazer o serviço para traficantes para quem ficara devendo por conta de outra vultosa apreensão de drogas que lhe rendeu muitos anos de cadeia, mais denotando que, ciente de toda a trama, como revelam as conversas por aplicativo extraídas de seu celular (fls. 508), era um elo da corrente de distribuição de drogas, aptas a abastecer muitas biqueiras e enriquecer muitos pesados traficantes.

E mais uma vez, a prova, no entanto, não elidiu a versão de Vinicius no sentido de que apenas fazia o serviço de transporte de passageiro por aplicativo e nada sabia sobre a droga colocada no veículo pelo passageiro Paulo Sergio, não havendo, pois, fundamento para que seja responsabilizado criminalmente.

Reputo, por fim, que não resultou caracterizado o delito autônomo de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, vez que não foi realizada qualquer investigação, atuando a polícia militar rodoviária repressivamente, e não ficou estreme de dúvidas que os réus Paulo Sérgio e Matheus tivessem se unido em vínculo subjetivo de associação, estabilizada e organizada, com o caráter de habitualidade, para o fim de comércio ilícito de drogas, como exige o tipo penal em apreço.

Precioso sobre o tema o ensinamento de Vicente Greco Filho:

Concurso de agentes. Poder-se-ia entender que também configuraria o crime o simples concurso de agentes, porque bastaria o entendimento de duas pessoas para a prática de uma conduta punível, prevista naqueles artigos, para incidência no delito agora comentado, em virtude da cláusula 'reiteradamente ou não'. Parece-nos, todavia, que não será toda vez que ocorrer concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a co-autoria.

Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em

seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples co-autoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. Destarte, imperativa a condenação, passando-se à individualização das penas. Considerando que as circunstâncias preponderantes, conforme artigo 42 da Lei nº 11.343/06, são desfavoráveis aos réus, notadamente pela vultosa quantidade de droga, pasta-base de cocaína, apta a abastecer o comércio espúrio em larga escala, fixo a pena-base para cada réu metade acima do patamar mínimo legal, ou seja, em sete anos e seis meses de reclusão e setecentos e cinquenta dias-multa.

Ante a confissão de Matheus, reduzo sua pena na segunda fase em um quinto, alcançando seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Quanto a Paulo, preponderante a circunstância agravante da reincidência específica sobre a confissão qualificada, aumento sua pena em mais um terço, atingindo dez anos de reclusão e ao pagamento de mil dias-multa, no piso legal.

Não sendo produzida qualquer prova de que o réu Matheus, primário e sem antecedentes, se dedique integralmente à atividade criminosa ou que integre organização criminosa, porém relevada a grande quantidade de drogas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo sua pena em um terço, alcançando quatro anos de reclusão e pagamento de quatrocentos dias-multa.

Como ensina Guilherme de Souza Nucci:

"(...) se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário, de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como a pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição da pena (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base (a primeira etapa da aplicação da pena, conforme artigo 68 do Código Penal). O contrário também se dá. Percebendo enorme quantidade de drogas, ainda que em poder de traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações com o crime organizado, pode reservar tal circunstância para utilização na diminuição da pena (ex.: um sexto)." (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 330).

Também Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, assim se posicionam:

"Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre as condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu, que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda. Na prática, então, a pena na verdade não será, por exemplo, no caput, de cinco a quinze anos, mas de um sexto a dois terços menor, a não ser que traga aos autos prova da reincidência, dos maus antecedentes ou de que o agente se dedique a atividade criminosa ou integre organização criminosa". (Lei de Drogas Anotada - Lei nº 11.343/2006 - São Paulo: Saraiva, 2007, p. 102).

Por fim, tratando-se de tráfico de drogas interestadual, incide a majorante prevista no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas, acrescentando um quarto às penas,

tornando-as definitivas em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa para Matheus, e doze anos de reclusão e mil e duzentos dias-multa para Paulo Sergio. Sem parâmetros para análise da situação econômica dos réus, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do valor do salário mínimo vigente na época dos fatos, consoante dispõe o artigo 49, parágrafo 1º, combinado com artigo 60, caput, ambos do Código Penal.

Por fim, malgrado o entendimento do STF que reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 11.343/2006 que vedavam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 33, parágrafo 4º, e artigo 44, parte final) para condenado por crime de tráfico ilícito de drogas (HC 97256-RS, Pleno, rel. Min. Ayres Britto, j. 26/08/2010), bem como a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, publicada em 16/02/2012, que suspendeu a eficácia de tal dispositivo com efeito erga omnes, no caso em apreço, ponderadas as circunstâncias judiciais, relevando uma vez mais a grande quantidade de droga, não se mostra razoável e conveniente a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos para o réu Matheus por não atender ao disposto no artigo 44, inciso III, do Código Penal, na medida em que tal benefício é insuficiente e inadequado qualitativamente à reprovação de tão nefasta conduta, ferindo o princípio da proporcionalidade, além de minimizar a função reprovadora da sanção penal, devendo iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- 1- condenar PAULO SÉRGIO ARAÚJO DA SILVA, qualificado nos autos, à pena segregativa de doze anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 1.200 dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;
- 2 - condenar MATHEUS DA SILVA SERRADILHA, qualificado nos autos, à pena segregativa de cinco anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, calculada no mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06;
- 3 - absolver VINÍCIUS GUSTAVO REIS, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do CPP.

Presos em flagrante e condenados, não poderão os réus Paulo Sérgio e Matheus recorrer em liberdade.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal, condenados, os réus arcarão com as custas processuais, observada a gratuidade de justiça.

Nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/2006, determino o perdimento, em favor da União, do dinheiro apreendido em poder dos réus.

Sejam os réus recomendados nos estabelecimentos prisionais em que se encontram e com o trânsito em julgado sejam expedidos mandados de prisão.

P. I . C.

Itatiba, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

PUBLICAÇÃO

Aos 25 de janeiro de 2022, recebi estes autos em cartório com a r. decisão supra, a qual publico em Cartório. Escrevente: